

刑法第65条について、学生A、B及びCが次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑩までの()内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、①から⑩までの()内にはそれぞれ異なる語句が入る。

【会話】

学生A. 私は、「違法の連帯性、責任の個別性」の原則を強調する立場から、(①)と考えます。

学生B. A君の見解には、(②)との批判がありますね。私は、刑法第65条第1項が「共犯とする」、同条第2項が「通常の刑を科する」とそれぞれ規定していることに着目し、(③)と考えます。

学生C. ただ、B君の見解には、(④)との批判がありますね。刑法第65条第1項が身分によって構成すべき犯罪を問題とし、同条第2項が身分によって刑の軽重がある犯罪を問題としていることに着目し、(⑤)と考えるべきではないかな。

学生B. でも、C君の見解にも、(⑥)との批判がありますね。ところで、C君の見解だと、甲が知人の乙を唆して乙の嬰兒の生存に必要な食事をさせなかった事例では、甲の罪責はどうなりますか。

学生C. 私は、刑法第217条(遺棄)と同法第218条(保護責任者遺棄等)の「遺棄」とは、行為者と要扶助者との間の場所的離隔を生じさせることをいい、同法第217条では作為による遺棄のみが処罰されていると考え、また、同法第218条の「必要な保護をしなかった」とは、場所的離隔を生じさせることなく要扶助者を不保護状態に置くことをいうと考えます。そうすると、同条の罪のうち、作為による保護責任者遺棄罪は(⑦)犯、保護責任者不保護罪は(⑧)犯になるため、乙とその嬰兒との間に場所的離隔が生じていない本件では、甲には(⑨)と考えます。

学生A. しかし、C君の見解では、甲が乙を唆して乙の嬰兒を山に捨てさせた事例では、甲に(⑩)ため、不均衡な結論になるのではないかな。私は、保護責任者という身分は、必要な保護をしなかったことの違法性を基礎付け、遺棄の違法性を加重するため、(⑪)と考えます。したがって、私の見解からは、いずれの事例でも、甲には(⑨)と考えます。

【語句群】

- 刑法第65条第1項は真正身分犯の成立及び科刑についての規定であり、同条第2項は不真正身分犯の成立及び科刑についての規定である
- 刑法第65条第1項は身分が違法性に関係する場合についての規定であり、同条第2項は身分が責任に関係する場合についての規定である
- 刑法第65条第1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定であり、同条第2項は不真正身分犯の科刑についての規定である
- 犯罪の成立と科刑が分離されることになる
- 真正身分犯が身分を連带的に作用させ、不真正身分犯が身分を個別的に作用させることの実質的根拠が明らかでない
- 身分が違法性に関係する場合と責任に関係する場合を区別することは困難
- 責任身分 h. 違法身分 i. 真正身分 j. 不真正身分
- 刑法第218条の罪の教唆犯が成立する
- 刑法第217条の罪の教唆犯が成立する

- ①b ⑤a ⑨k 2. ②d ⑥e ⑩h 3. ②f ⑦i ⑧j
4. ③c ④d ⑪g 5. ③c ⑥f ⑩l

No174

共通R3-15

共犯と身分

正解

1

正答率

61%

() には順に、「① = b、② = f、③ = c、④ = d、⑤ = a、⑥ = e、⑦ = j、⑧ = i、⑨ = k、⑩ = l、⑪ = h」が入り、組合せとして正しいものは「①b ⑤a ⑨k」であり、したがって、正解は肢1となる。

①について

①には、65条に関するAの見解に関する語句が入る。Aの第1発言をみると、「違法の連帯性、責任の個別性」の原則を強調する立場に立つと述べていることから、Aは、身分につき違法が連带的に作用するものと、責任が個別的に作用するものとに分けて65条を解釈することが推測される。同条の解釈を示す【語句群】abcのうち、それに最も適合するのはbである。したがって、①には「b. 刑法第65条第1項は身分が違法性に関係する場合についての規定であり、同条第2項は身分が責任に関係する場合についての規定である」が入る。

②について

②には、Aの見解に対する批判に関する語句が入る。Aの見解は、65条1項は身分が違法性に関係する場合についての規定であり、同条2項は身分が責任に関係する場合についての規定であるとする。批判となり得る【語句群】defのうち、Aの見解に対する批判として最も適切なものはfである。したがって、②には「f. 身分が違法性に関係する場合と責任に関係する場合を区別することは困難」が入る。

③について

③には、65条に関するBの見解に関する語句が入る。Bの第1発言をみると、65条1項が「共犯とする」、同条2項が「通常の刑を科する」とそれぞれ規定していることに着目すると述べていることから、Bは、同条1項を共犯の成立、同条2項を科刑の問題とに分けて解釈することが推測される。同条の解釈を示す【語句群】abcのうち、それに最も適合するのはcである。したがって、③には「c. 刑法第65条第1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定であり、同条第2項は不真正身分犯の科刑についての規定である」が入る。

④について

④には、Bの見解に対する批判に関する語句が入る。Bの見解は、65条1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定であり、同条2項は不真正身分犯の科刑についての規定であるとする。批判となり得る【語句群】defのうち、Bの見解に対する批判として最も適切なものはdである。したがって、④には「d. 犯罪の成立と科刑が分離されることになる」が入る。

⑤について

⑤には、65条に関するCの見解に関する語句が入る。「①から⑪までの() 内にはそれぞれ異なる語句が入る」(設問柱書のお書) ところ、65条の解釈を示す【語句群】abcのうち、すでにbは①に、cは③に入ることが確定しているので、残ったaが⑤に入ることがわかる。また、Cの第1発言をみると、65条1項が身分によって構成すべき犯罪を問題とし、同条2項が身分によって刑の軽重がある犯罪を問題としていることに着目すると述べていることから、Cは、同条1項を構成的身分(真正身分)、同条2項を加減的身分(不真正身分)とに分けて解釈することが推測される。同条の解釈を示す【語句群】abcのうち、それに最も適合するのはaである。した

がって、⑤には「a. 刑法第 65 条第 1 項は真正身分犯の成立及び科刑についての規定であり、同条第 2 項は不真正身分犯の成立及び科刑についての規定である」が入る。

⑥について

⑥には、C の見解に対する批判に関する語句が入る。「①から①①までの（ ）内にはそれぞれ異なる語句が入る」（設問柱書のお書）ところ、批判となり得る【語句群】d e f のうち、すでに f は②に、d は④に入ることが確定しているので、残った e が⑥に入ることがわかる。また、C の見解は、65 条 1 項は真正身分犯の成立及び科刑についての規定であり、同条 2 項は不真正身分犯の成立及び科刑についての規定であるとする。批判となり得る【語句群】d e f のうち、C の見解に対する批判として最も適切なものは e である。したがって、⑥には「e. 真正身分犯が身分を連带的に作用させ、不真正身分犯が身分を個別的に作用させることの実質的根拠が明らかでない」が入る。

⑦⑧について

⑦⑧には、C の見解による、作為による 218 条の身分の性質に関する語句が入る。まず、218 条の身分の性質を示す【語句群】としては g h i j があるところ、C の見解は、65 条につき真正身分犯か不真正身分犯かで分けることから、⑦⑧には g h ではなく、i j のいずれかが入ることがわかる。それを踏まえて C の第 2 発言をみると、C の見解のポイントは、(ア)「遺棄」(217 条、218 条)と「必要な保護をしなかった」(218 条)は場所的離隔を生じさせるか否かで区別されること、(イ)単純遺棄罪 (217 条)では作為による遺棄のみが「遺棄」として処罰されること、の 2 点である。そうすると、作為による遺棄によって場所的離隔を生じさせた場合、保護責任者の身分があれば保護責任者遺棄罪、身分がなければ単純遺棄罪が成立するので、身分の有無によって刑が加減される関係にある。すなわち、作為による「遺棄」との関係では、保護責任者は不真正身分 (j) となる。これに対して、場所的離隔を生じさせることなく要扶助者を不保護状態に置いた場合、保護責任者の身分があれば保護責任者不保護罪が成立するが、身分がなければ保護責任者不保護罪は成立しない(場所的離隔が生じていないので単純遺棄罪も成立しない)ので、身分の有無によって犯罪を構成するかどうかに分かれる関係にある。すなわち、「必要な保護をしなかった」との関係では、保護責任者は真正身分 (i) となる。したがって、⑦には「j. 不真正身分」が、⑧には「i. 真正身分」が入る。

⑨について

⑨には、事例 (学生 B 第 2 発言) について、C の見解から検討した場合の甲の罪責に関する語句が入る。同事例の正犯乙はその嬰兒の保護責任者であるところ、生存に必要な食事をさせないことは、場所的離隔を生じさせることなく要扶助者を不保護状態に置くものであり、「必要な保護をしなかった」に当たり、保護責任者不保護罪が成立する。そして、C の見解によれば、同罪は真正身分犯であるから、非身分者甲には 65 条 1 項が適用される。その結果、甲には保護責任者不保護罪 (218 条) の教唆犯が成立する。したがって、⑨には「k. 刑法第 218 条の罪の教唆犯が成立する」が入る。

⑩について

⑩には、事例 (学生 A 第 2 発言) について、C の見解から検討した場合の甲の罪責に関する語句が入る。「①から①①までの（ ）内にはそれぞれ異なる語句が入る」（設問柱書のお書）ところ、罪責に関する【語句群】k l のうち、すでに k が⑨に入ることが確定しているので、残った l が⑩に入ることがわかる。また、同事例の正犯乙はその嬰兒の保護責任者であるところ、嬰兒を山に捨てることは行為者と要扶助者との間の場所的離隔を生じさせるものであり、「遺棄」に当たり、保護責任者遺棄罪が成立する。そして、C の見解によれば、同罪は不真正身分犯であるから、非身分者甲には 65 条 2 項が適用される。その結果、甲には単純遺棄罪 (217 条) の教唆犯が成立する。し

たがって、⑩には「1. 刑法第217条の罪の教唆犯が成立する」が入る。

⑪について

⑪には、Aの見解による、保護責任者という身分の性質に関する語句が入る。Aの第2発言をみると、保護責任者という身分は、必要な保護をしなかったことの違法性を基礎付け、遺棄の違法性を加重するものと述べていることから、違法身分(h)と考えていることがわかる。また、保護責任者を違法身分と考えると、保護責任者不保護の事例(学生B第2発言)と保護責任者遺棄の事例(学生A第2発言)のいずれの事例でも、65条1項の適用により、甲には218条の罪の教唆犯が成立する(⑨k)ため、学生Aの発言内容とも合致する。したがって、⑪には「h. 違法身分」が入る。